

## ILICITUDE - INTRODUÇÃO

Segundo o conceito analítico do crime:

| Elementos do crime                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fato Típico                                                                                                                                       | Antijuridicidade (ilícitude)                                                                                                                                                                                                                                                         | Culpabilidade                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Conduta</li><li>• Resultado</li><li>• Relação de causalidade (nexo causal)</li><li>• Tipicidade</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• É presumida</li></ul> <p>Excludentes de ilicitude:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Legítima defesa</li><li>• Estado de necessidade</li><li>• Estrito cumprimento do dever legal</li><li>• Exercício regular de direito</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Imputabilidade</li><li>• Potencial consciência da ilicitude</li><li>• Exigibilidade de conduta diversa</li></ul> |

### ILICITUDE

Conceito: contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico.

Se há tipicidade da conduta, presume-se que há ilicitude. No entanto, esta presunção é relativa, pois eventualmente poderá incidir uma excludente de ilicitude. A antijuridicidade presumida está de acordo com a teoria da indiciabilidade, também conhecida por *ratio cognoscendi*.

#### Ilícitude genérica vs ilícitude específica

Ilícitude genérica – Análise da ilicitude é feita após a adequação do fato ao tipo penal. A ilicitude é analisada fora do tipo penal, para demonstrar que há contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico.

Ilícitude específica – Análise da ilicitude é feita no próprio tipo penal. A ilicitude é analisada como um elemento do tipo penal.

Exemplos:

Violação de correspondência

**Art. 151.** Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem;

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## Exercício arbitrário das próprias razões

**Art. 345.** Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite;

## Estelionato

**Art. 171.** Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.



## Exclusão de ilicitude

**Art. 23.** Não há crime quando o agente pratica o fato:

I – em estado de necessidade;

II – em legítima defesa;

III – em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Causas  
genéricas,  
ou gerais

Podem incidir sobre qualquer infração penal

## CAUSAS ESPECÍFICAS OU ESPECIAIS DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE

Têm aplicação específica a determinados tipos penais. Estão presentes na parte especial do CP e na legislação penal especial.

São exemplos:

CP:

**Art. 128.** Não se pune o aborto praticado por médico:

Aborto necessário

I – se não há outro meio de salvar a vida da gestante;

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro

II – se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.



## Exclusão do crime

CP:

**Art. 142.** Não constituem injúria ou difamação punível:

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)

- I – a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador;
  - II – a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar;
  - III – o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício.
- Parágrafo único. Nos casos dos ns. I e III, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade.

Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais):

**Art. 37.** Não é crime o abate de animal, quando realizado:

- I – em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família;
- II – para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente;
- III – (VETADO)
- IV – por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.

## CAUSAS SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DE ILICITUDE

A lei não prevê todas as hipóteses de exclusão da ilicitude.

Algumas podem ser fruto da evolução da sociedade e de novas construções doutrinárias.

Hipótese mais aceita de causa supralegal de exclusão de ilicitude:

- Consentimento do ofendido para que o consentimento da vítima seja excludente de ilicitude, são necessários os seguintes requisitos:

1. Em relação a bens disponíveis;
2. Tem de ser manifestado expressamente;
3. A manifestação deve ser livre de coação;
4. A parte deve ser plenamente capaz; e
5. A manifestação deve ser prévia ou concomitante. Não é possível a manifestação ou concordância da vítima posteriormente à prática do crime.

## ASPECTOS PROCESSUAIS PENAIS DA ILICITUDE

- Ônus da prova sobre a existência da causa de exclusão da ilicitude é da defesa. O MP tem o ônus de provar que o agente praticou um fato típico e a culpabilidade do agente. Lembre-se de que a ilicitude é presumida.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



25m



30m

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)

- Diante da dúvida do juiz se o agente incorreu ou não em excludente de ilicitude, deve absolver ou condenar? Deverá absolver o réu, prevalecendo a excludente da ilicitude (*in dubio pro reo*). Veja a previsão legal do CPP:

“**Art. 386.** O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...)

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), **ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;**”



35m

### Delegado de Polícia pode deixar de autuar em flagrante diante do reconhecimento de uma excludente de ilicitude?

- 1ª Corrente: Não
- Fundamento: Art. 310, Parágrafo único – Função do juiz.
- 2ª Corrente: Sim
- Fundamentos: encarceramento indevido do inocente.

**Art. 302.** Considera-se em flagrante delito quem:

I – está cometendo a infração penal;

II – acaba de cometê-la;

III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.



40m



## DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/STJ/ANALISTA/2018) A respeito da culpabilidade, da ilicitude e de suas excludentes, julgue o item que se segue.

Conforme a doutrina pátria, uma causa excludente de antijuridicidade, também denominada de causa de justificação, exclui o próprio crime.



## COMENTÁRIO

Se há exclusão da ilicitude, o fato típico isoladamente nunca constituirá crime (teoria bipartida).

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)

2. (CESPE/TJDFT/JUIZ/2016) De acordo com o CP, constituem hipóteses de exclusão da antijuridicidade
- o estrito cumprimento do dever legal e o estado de necessidade.
  - a insignificância da lesão e a inexigibilidade de conduta diversa.
  - a legítima defesa putativa e o estrito cumprimento do dever legal.
  - o estado de necessidade e a coação moral irresistível.
  - o exercício regular de direito e a inexigibilidade de conduta diversa.

### COMENTÁRIO

O art. 23 do CP traz o rol das excludentes de ilicitude. Este rol não é exaustivo, trazendo causas genéricas de exclusão da ilicitude.

3. (IBADE/PCAC/DELEGADO/2017) Acerca do consentimento real do ofendido, é correto afirmar que:
- o consentimento, para ser válido, pressupõe que o titular do bem jurídico atingido possua capacidade de entendimento quanto ao caráter e à extensão da autorização.
  - invariável e indiscutivelmente, a vida humana é um bem jurídico indisponível, de sorte que não pode ser objeto de consentimento para sua extinção.
  - se uma pessoa autoriza que médico aplique determinado medicamento em seu corpo, suportando efeitos severamente prejudiciais à saúde inerentes ao uso da substância, os quais desconhecia, o consentimento real se mantém válido, pois é a vítima quem deve buscar todas as informações sobre as consequências de sua autorização.
  - De acordo com a doutrina de Claus Roxin, o consentimento do ofendido exclui a antijuridicidade da conduta praticada, jamais recaindo sobre a esfera da tipicidade.
  - em regra, o consentimento deve ser anterior à ação consentida, mas nada impede seu reconhecimento mesmo quando posterior, como no caso de ausência de representação do ofendido no crime de lesão corporal leve, hipótese em que o crime deixa de existir.

### COMENTÁRIO

De fato, a vida humana é um bem jurídico indisponível. O detalhe (e a pegadinha) da banca é a hipótese da eutanásia; o paciente, para que sua manifestação seja livre de coação, deve conhecer todos os efeitos do medicamento; Roxin entende que o consentimento como exclusão



45m

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)

da antijuridicidade pode recair sobre a esfera da tipicidade (inclusive, teorias como a imputação objetiva e da tipicidade conglobante de Zaffaroni transportam algumas causas de excludentes da ilicitude para a análise do fato típico); e o consentimento não pode ser posterior.

4. (FUNCAB/PCES/DELEGADO/2013) Geraldino permitiu seu encarceramento pelo patologista André, para se submeter a uma experiência científica. Ao terminar o período da experiência, Geraldino procurou a delegacia de polícia da circunscrição de sua residência, alegando que fora vítima de crime, em face do seu encarceramento. Do relato apresentado, conclui-se:
- a. Não há crime, pois o consentimento do ofendido excluiu a ilicitude.
  - b. André praticou o crime de sequestro ou cárcere privado qualificado, preceituado no artigo 148, § 1º, II (se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital) do CP.
  - c. André praticou o crime de sequestro ou cárcere privado qualificado, preceituado no artigo 148, § 2º (se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral) do CP.
  - d. André praticou o crime de lesão corporal, que absorve o crime de sequestro ou cárcere privado.
  - e. André praticou os crimes de lesão corporal e de sequestro ou cárcere privado, em concurso material.

### COMENTÁRIO

O consentimento foi prévio e o bem jurídico é disponível (liberdade).



5. (CESPE/TRF1/ANALISTA/2017) Acerca da antijuridicidade e das causas de exclusão no direito penal, julgue o item subsequente.

O consentimento do ofendido é uma excludente de antijuridicidade e poderá ser manifestado antes, durante ou depois da conduta do agente.

### COMENTÁRIO

O consentimento da vítima é uma excludente supralegal e pode ser manifestado antes ou durante a conduta do agente.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## GABARITO

1. C
2. a
3. a
4. a
5. E

---

*Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.*

*A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.*

---

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |